

Súd: Krajský súd Bratislava  
Spisová značka: 2Cob/60/2023  
Identifikačné číslo súdneho spisu: 1116213513  
Dátum vydania rozhodnutia: 11. 06. 2024  
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Krišková  
ECLI: ECLI:SK:KSBA:2024:1116213513.1

## ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubice Kriškovej a členiek senátu JUDr. Nory Vladovej a JUDr. Viery Malinowskej v právnej veci žalobcu: BK, a.s., so sídlom Dopravná 19, 921 01 Piešťany, IČO: 36 275 522, zastúpeného: CLS Čavojský & Partners, s.r.o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, proti žalovanému: Centroom, s. r. o., so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 36 251 607, zastúpenému: JUDr. Ján Benčura, advokát, so sídlom Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, o zaplatenie 91.513,09 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu a žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 32Cb/93/2016 zo dňa 16.11.2022 takto

### rozhodol:

I. Krajský súd v Bratislave rozsudok Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 32Cb/93/2016 zo dňa 16.11.2022 v napadnutej časti výroku I., ktorým uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 16.086,34 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8% ročne zo sumy 16.086,34 Eur od 14.5.2016 do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozsudku **p o t v r d z u j e**.

II. Krajský súd v Bratislave rozsudok Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 32Cb/93/2016 zo dňa 16.11.2022 v napadnutom výroku II., ktorým zamietol žalobu v časti o zaplatenie 36.605,24 Eur s prísl. a súvisiacom výroku III. **z r u š u j e** a vec **v r a c i a** súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

### o d ô v o d n e n i e :

1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodol, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobkyni sumu 54.539,34 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8% ročne zo sumy 54.539,34 Eur od 14.05.2016 do zaplatenia, a to do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku (výrok I.). Vo zvyšku súd žalobu žalobkyne zamietol (výrok II.) a rozhodol, že žalovaná je povinná nahradiť žalobkyni trovy konania v rozsahu 19,20%, pričom o výške tejto náhrady bude rozhodnuté Okresným súdom Bratislava I samostatným uznesením (výrok III.).

2. Súd prvej inštancie v odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa sa žalobou doručenou Okresnému súdu Bratislava I 22.06.2016 domáhala proti žalovanej zaplatenia sumy 91.513,09 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,05% ročne zo sumy 91.513,09 Eur od 06.07.2015 do zaplatenia, zaplatenia paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v sume 40,- Eur a náhrady trov konania.

3. Podľa súdu prvej inštancie medzi stranami sporu nebolo sporné, že bola uzavretá zmluva o dielo 2/2009 16.11.2009 v znení jej dodatku č. 1 z 30.06.2010 a dodatku č. 2 z 02.02.2011. Spornosť spočívala v oprávnení žalovanej uspokojiť svoje nároky z bankovej záruky, t. j. predmetom sporu je posúdenie, či žalovaná oprávnene získala plnenie z bankovej záruky, pretože v opačnom prípade je povinná toto plnenie žalovanej vrátiť.

4. Súd prvej inštancie aplikoval na zistený skutkový stav ustanovenia § 261 ods. 1, § 1 ods. 2, § 313, § 319, § 321 ods. 4, § 369 ods. 1, § 369c ods. 1, § 536, § 537 ods. 3, § 550, § 551 ods. 1 a 2, § 560 ods. 1, § 561, § 786k ods. 2 Obchodného zákonníka.

5. Súd prvej inštancie poukázal na to, že strany sporu uzavreli zmluvu o dielo 2/2009 16.11.2009. Dodatok č. 1 k tejto zmluve bol uzatvorený 30.06.2010 a Dodatok č. 2 k tejto zmluve bol uzatvorený 02.02.2011. Je preto nepochybné, že ide o záväzkový vzťah vzniknutý pred 01.02.2013. Uviedol, že žalobkyňa preto nemá podľa bodu 32. a 33. tohto rozsudku nárok na úroky z omeškania vo výške 9,05% ročne, ale len na výšku úroku z omeškania o 8 percentuálnych bodov vyššieho ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Súd žalobkyni nepriznal paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v sume 40,- Eur, ktorá bola uplatnená podľa právnych noriem uvedených v bode 24. a 34. tohto rozsudku po zohľadnení skutočnosti, že žalovaná sa dostala s úhradou žalovanej sumy do omeškania, pretože paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky je povinnosťou zo zodpovednosti za porušenie záväzkov, a keďže zmluva o dielo v znení jej dodatkov bola uzavretá pred 1. februárom 2013, tak v zmysle § 768k ods. 2 Obchodného zákonníka (bod 31. tohto rozsudku) je potrebné vychádzať z predpisov účinných do 31. januára 2013. Obchodný zákonník v znení účinnom do 31. januára 2013 paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky neupravoval, a preto žalobkyňa na ňu nemá nárok. Na základe uvedeného súd žalobu žalobkyne v tejto časti zamietol.

6. Ďalej poukázal na to, že v čl. V ods. 4 zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli, že 5% z ceny diela (bez DPH) je zádržné a 5% z ceny diela (bez DPH) je garančná zábezpeka. Zádržné a garančnú zábezpeku podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo zádržného a z garančnej zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, plynúce z nedodržania doby výstavby zhotoviteľom a náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy. Garančné zádržné vo výške 5% z ceny diela je zhotoviteľ oprávnený nahradiť bankovou zárukou vystavenou v prospech objednávateľa. V rámci dohody o urovnaní zo 04.02.2011 objednávateľ a zhotoviteľ v čl. III ods. 7 vyhlásili, že správna výška garančnej zábezpeky podľa čl. V bod 19 písm. b) zmluvy o dielo je 91.513,09 Eur. Banka v liste z 26.05.2015 potvrdila, že žalovaná listom zo 04.05.2015 a listom z 20.05.2015 požiadala banku o plnenie z bankovej záruky spolu vo výške 91.513,09 Eur (04.05.2015 38.591,85 Eur a 20.05.2015 52.921,24 Eur). Banka 07.05.2015 a 21.05.2015 žalovanej poskytla plnenie z bankovej záruky.

7. Súd prvej inštancie uviedol, že ak žalovaná dosiahla na základe bankovej záruky plnenie, na ktoré nemala nárok podľa svojho vzťahu k žalobkyni, je žalobkyňa oprávnená požadovať, aby jej toto plnenie bolo vrátené. V tomto smere súd nespochybňuje dohodu medzi stranami sporu v čl. V ods. 4 zmluvy o dielo, oprávňujúce uspokojiť jednostranným zápočtom z bankovej záruky nárok na zmluvnú pokutu, náhradu škody, nároky z väd diela. Uvedené potvrdzuje aj čl. VI ods. 5 zmluvy o dielo, v ktorom je upravené právo žalovanej uspokojiť tieto nároky z bankovej záruky. Súd poukazuje na tvrdenie žalobkyne (bod 4. tohto rozsudku), že žalovaná voči nej nikdy neuplatnila nárok na náhradu škody a ani nárok na zmluvnú pokutu. Tieto námietky nemajú právnu relevanciu, pretože v konaní nebolo tvrdené, že banková záruka bola viazaná na iné podmienky než na zaplatenie na prvú výzvu a bez námietok. V zmluve o dielo rovnako nie je žiadne ustanovenie o tom, že pred uspokojením sa žalovanej z bankovej záruky je potrebné žalobkyňu osobitnou výzvou vyzývať na úhradu zmluvnej pokuty, či náhrady škody. Uvedené potvrdzuje aj Obchodný zákonník v § 317, kde ustanovuje, že predchádzajúca výzva, aby dlžník splnil svoj záväzok, sa vyžaduje, len keď to určuje záručná listina. Súdu síce bola predložená banková záruka, ale len ako nevyplnené tlačivo, v ktorom sa uvádza, že banka plní po prijatí prvej písomnej výzvy bez námietok. Ak žalobkyňa tvrdila neoprávnenosť čerpania bankovej záruky, bolo jej povinnosťou súdu predložiť vyplnené tlačivo bankovej záruky, pretože obsah spisu nasvedčuje jedine tomu, že išlo o bankovú záruku na prvú výzvu a bez námietok. Súd ale zdôrazňuje, že ak žalobkyňa namieta neoprávnený postup žalovanej pri siahnutí na bankovú záruku, zaťažuje dôkazné bremeno predovšetkým žalovanú preukázať, že na uspokojenie svojich nárokov bola oprávnená, pretože z týchto tvrdení vyvodzuje priaznivé dôsledky pre seba.

8. V zmysle listu z 20.05.2015 si žalovaná uplatnila bankovú záruku okrem iného na úhradu náhrady škody z vadného plnenia diela (praskliny a dilatácie) v bytoch 6.01, 6.02, 6.03, 6.06, 6.08 a 6.9 vo výške 125.812,70 Eur. Podklad náhrady škody je podľa spomenutej listiny v čl. VI ods. 5 zmluvy o dielo. Zmluva o dielo v tomto ustanovení síce umožňuje uplatniť žalovanej náhradu škody, ale toto oprávnenie viaže výlučne na odstraňovanie následkov vadného plnenia žalobkyne. Bolo preto povinnosťou žalovanej súdu preukázať výšku vzniknutej škody a v čom presne táto škoda spočíva. V podaní zo 07.10.2021 žalovaná uviedla, že náhrada škody predstavuje poskytnutú zľavu z ceny bytov kupujúcim v dôsledku neodstránených závad bytov 6.01, 6.02, 6.03, 6.06, 6.08, 6.09. Za týmto účelom predložila súdu tabuľku ceny bytov pred a po zľave spolu s čestným vyhlásením AMD Partners, s. r. o. z 05.10.2021 o tom, že tejto spoločnosti žalovaná poskytla zľavu z ceny bytu vo výške 26.734,70 Eur. Tieto dôkazy nepostačujú na preukázanie výšky škody, pretože ide len o tvrdenia žalovanej, ktoré podporuje nič nepreukazujúcou tabuľkou s číslami, ktoré nemajú oporu v iných dôkazoch. Predovšetkým ale je tento postup žalovanej v rozpore so samotnou zmluvou o dielo, pretože táto síce v čl. V ods. 4 oprávňuje žalovanú uspokojiť jednostranným zápočtom z bankovej záruky nárok na náhradu škody, ale toto oprávnenie je potrebné vykladať v súlade s čl. VI ods. 5 zmluvy o dielo, kedy nárok na náhradu škody zmluva viaže na odstraňovanie následkov vadného plnenia žalobkyne. To znamená, že žalovaná, ak vynaložila náklady na odstránenie väd, ktoré mala odstrániť žalobkyňa, tak jej týmto postupom vznikne škoda, ktorú si môže vykryť uspokojením sa z bankovej záruky. V žiadnom prípade nemožno uvedené vykladať tak, že náhrada škody má pokrývať ušlý zisk žalovanej z predaja bytov so zľavou pre neodstránené vady. Keďže zmluva o dielo podľa súdu nepripúšťa takto široko koncipovanú náhradu škody, bolo uspokojenie sa žalovanej z bankovej záruky titulom náhrady škody neoprávnené a žalovaná musí tieto prostriedky žalobkyni vrátiť.

9. Súd prvej inštancie konštatoval, že mu bolo predložené potvrdenie o odovzdaní realizačnej projektovej dokumentácie stavby „SO 110 Polyfunkčný objekt - Piešťany“ zo 16.11.2009. Z tohto potvrdenia ale podľa súdu nevyplýva, že žalobkyni bola odovzdaná aj časť o statike. Uvedené potvrdil aj svedok Z.. W. Š.. Z jeho výpovede vyplynulo, že žalobkyňa nemala ľudia a nemohla dokončiť výstavbu hrubej stavby. Nastúpila len na dokončenie objektu. Čiže pre dokončenie objektu dostala dokumentáciu, týkajúcu sa ich rozsahu - architektúru a všetky profesie. Nebola jej odovzdaná statika, tú ani nepožadovala. Rovnako v zápise z kontrolného dňa stavby č. 26 z 26.11.2009 sa uvádza, že žalobkyni bola odovzdaná projektová dokumentácia bez statiky. Z uvedeného potom možno vyvodiť záver, že ustanovenia zmluvy o dielo súdom uvádzané v bode 45. tohto rozsudku nedopadajú na tento spor pokiaľ ide o chyby v statike, resp. povinnosti žalovanej vo vzťahu k statike. Žalobkyňa vykonávala len dokončovacie práce, nerealizovala hrubú stavbu, a preto ani nebolo potrebné jej predkladať statiku. Zmluva o dielo teda vylučuje, aby žalobkyňa vykonávala práce na diele, kde je potrebná statika - porovnaj bod 44. tohto rozsudku. Z uvedeného dôvodu je potom logickým následkom, že žalovaná žalobkyni neodovzdala projektovú dokumentáciu v časti statiky. Súdu bola predložená aj listina z 21.04.2010 „výkony dodávok, ktoré nie sú predmetom záruky podľa ZoD“, v ktorej sa výslovne uvádza, že zo zodpovednosti za vady diela sú vyňaté všetky výkony stavebných prác a dodávok, ktoré boli zrealizované do 11.11.2019, alebo neboli zrealizované zhotoviteľom stavby podľa tejto zmluvy o dielo, a to konkrétne hrubé terénne úpravy, piloty, podkladový betón, ležaté rozvody pod podkladovým betónom, zvislé monolitické konštrukcie, vodorovné monolitické konštrukcie, monolitické konštrukcie, murivo Porotherm v určenom rozsahu, murivo Silka v určenom rozsahu a priečky Ytong v určenom rozsahu. V zápise o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby z 26.11.2009 je uvedené, že došlo k prevzatí a odovzdaniu hrubej stavby skelet, obvodovej steny, priečky bytov (Silka) a ostatné priečky (Ytong). Žalobkyňa teda v rámci predloženej projektovej dokumentácie statiku nedostala a nebol ani dôvod jej statiku predkladať, pretože hrubú stavbu nerealizovala - realizovala len dokončovacie práce. Nemožno sa preto dovolávať čl. III zmluvy o dielo - presnejšie povinnosti preskúmať projektovú dokumentáciu a hlásiť jej chyby žalovanej, a to v časti, ktorú žalobkyňa od žalovanej nedostala (statika) a pre svoju činnosť ani nepotrebovala.

10. Podľa súdu prvej inštancie z vykonaného dokazovania vyplynulo, že žalovaná nesprávne posúdila vznik trhlin (prasklín, puklín) na diele. Dielo malo od začiatku problém s tým, ako bola postavená hrubá stavba. Vyjadrenia odborníkov spočiatku vychádzali z nerovnomerného sadania stavby, čo R.. U. ešte v roku 2018 označil za správny záver. S odstupom času v roku 2015, v roku 2016 a v roku 2017 vypracované posudky (bod 47. a 50. rozsudku súdu prvej inštancie) dospeli k záveru o chybnnej statike stavby. Pre posúdenie tohto sporu nie je smerodajné, či išlo o nerovnomerné sadanie stavby alebo chyby v statike, pretože aj jedno aj druhé vylučuje zodpovednosť žalobkyne za vzniknuté vady (bod 46. rozsudku súdu prvej inštancie - listina z 21.04.2010 „výkony dodávok, ktoré nie sú

predmetom záruky podľa ZoD), ktoré majú pôvod či už v nesprávnej statike alebo v nerovnomernom sadaní stavby. Žalovaná síce v roku 2010 nemohla mať vedomosť o chybnej statike stavby, ale mala vedomosť o odbornom posudku číslo 1/2010 z 22.07.2010 s jednoznačným záverom, že najzávažnejšou príčinou vzniku trhlin na nenosných murovaných konštrukciách je nerovnomerné sadnutie najviac zaťažených stĺpov železobetónového skeletu v strednej osi B oproti krajným osiam A a B. Riešitelia pritom predpokladali ďalšie poškodenie nenosných konštrukcií v objekte a neodporúčali kozmetické úpravy murovaných priečok. Žalovaná síce poukazovala na vyjadrenia Baumiť, spol. s r. o. z 08.07.2010 a Xella Slovensko, spol. s r. o. z 13.07.2010, ale aj tieto pri trhlínach väčšieho rozsahu pripustili ako príčinu dotvarovanie a deformáciu staticky nosnej konštrukcie. Žalovaná síce argumentovala, že postupovala podľa odporúčania v posudku číslo 1/2010 z 22.07.2010, t. j. spôsob realizácie priečok, ale tento bod zároveň hovorí, že ide o realizáciu bez odstránenia príčiny vzniku trhlín. Žalobkyňa pritom opakovane upozorňovala na trhliny a priehyby a odmietala svoju zodpovednosť za vzniknutý stav. Podľa zmluvy o dielo (čl. VI ods. 9) je síce žalobkyňa povinná odstrániť aj vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ale len v tom prípade, že odstránenie neznesie odklad. Žalovaná pritom v rámci súdneho konania nijako nešpecifikovala, odstránenie ktorých väd nezneslo odklad - predovšetkým pri prasklinách. Okrem toho čl. VI ods. 1 zmluvy o dielo vylučuje zodpovednosť žalobkyne za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí vypracovaných žalovanou a žalobkyňa ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohla zistiť ich nevhodnosť ani pri realizácii diela alebo na ne písomne upozornila žalovanú do 7 pracovných dní odo dňa, keď ich pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti mala zistiť, ale žalovaná na ich použitie trvala. Žalobkyňa upozornila žalovanú na priehyby 26.11.2009, pričom statiku k dispozícii nemala. Opakovane boli zaznamenávané pukliny, pričom žalovaná vydala pokyn na pokračovanie v prácach. Uvedená situácia preto podľa súdu vylučuje zodpovednosť žalobkyne za statické vady.

11. Podľa súdu prvej inštancie žalobkyňa si splnila svoje povinnosti, keď už 26.11.2009, teda v deň prevzatia rozostavanej hrubej stavby poukázala na nerovnosti stropov vykazujúcich priehyby 4 - 5 cm. Žalovaná žalobkyňu ani len neodovzdala statiku diela, a preto očakávať od žalobkyne dôkladné zhodnotenie statiky je nedôvodné. Navyše, ako už súd opakovane uviedol, žalobkyňa neniesla zodpovednosť za statické vady, resp. za vady vzniknuté v dôsledku nerovnomerného sadania stavby, pretože je to vylúčené listinou z 21.04.2010 „výkony dodávok, ktoré nie sú predmetom záruky podľa ZoD“. V stavebnom denníku sú následne riadne zaznačované vznikly pukliny, pričom žalovaná trvala na realizácii diela. Je preto naplnená aj dikcia § 551 Obchodného zákonníka, kedy žalobkyňa listom z 21.07.2010 upozornila objednávateľa na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa a pokynov na vykonanie diela. Keďže žalovaná trvala na vykonaní diela, nemôže žalobkyňa zodpovedať za tie vady diela, ktoré majú pôvod v statike. Za daných okolností sú naplnené aj podmienky § 561 Obchodného zákonníka, čo tiež vylučuje zodpovednosť žalobkyne za vady statického rázu.

12. Vychádzajúc z listov žalovanej adresovaných banke na zaplatenie bankovej záruky zo 04.05.2015 a z 20.05.2015, žalovaná tvrdila neodstránenie nasledujúcich väd: a) oprava odlepenej dlažby na balkóne č. 5.6, b) oprava prasklín na fasáde polyfunkčného domu, c) oprava zatečených rohov v byte č. 7.04, d) oprava prasklín na 2., 3. a 4. nadzemnom podlaží, e) oprava prasklín, dilatácií, odpadnutých omietok na 2., 3., 4. nadzemnom podlaží a f) oprava prasklín, dilatácií a odlepených dlažieb v bytoch č. 3.4, 3.6, 4.2, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.1, 7.6. Podaním z 23.08.2019 a zo 07.10.2021 žalovaná špecifikovala, že vada b) je reklamácia č. 03/02/2015 Šr z 20.02.2015 - odstránenie 786,40 Eur, vada a) je reklamácia č. 03/11/2012 Šr z 22.11.2012 - odstránenie 335,51 Eur, vada c) je reklamácia č. 01/08/2014 Šr z 06.08.2014 - odstránenie 35,- Eur. Žalovaná pripočítala aj sumu 825,- Eur za pasportizáciu puklín na 2., 3. a 4. nadzemnom podlaží a za spracovanie prehľadu reklamačných konaní. Spolu ide o sumu 1.979,91 Eur, pričom žalovaná si z bankovej záruky uplatnila sumu 1.981,61 Eur. Pri zvyšných vadách žalovaná nešpecifikovala o aké reklamácie (číselné označenie) išlo. Uviedla však, že vynaložila sumu 3.798,- Eur a 10.670,24 Eur. V zmysle prehľadu reklamácií reklamácia č. 03/02/2015 spočíva v pukline na fasáde (v liste č. 03/02/2015 Šr je uvedené na fasáde polyfunkčného domu v rohoch okien sa vytvorili pukliny na zatepľovacom systéme, na 3. a 4. nadzemnom podlaží vznikli aj horizontálne pukliny na miestach styku tehlového muriva a stropnej betónovej dosky), reklamácia č. 03/11/2012 spočíva v odlepenej dlažbe v byte 5.6 a reklamácia č. 01/08/2014 v zle spádovanom balkóne a zavlhnutej stene (byt 7.4). Odlepenie dlažby v byte 5.6 a zatečenie rohu v byte 7.04 považoval súd za dostatočne určitú reklamáciu, námietka žalobkyne je preto v tomto smere nedôvodná.

13. Keďže pri vadách uvádzaných v liste z 20.05.2015 a ani počas súdneho konania žalovaná nešpecifikovala presne o aké vady ide (presné vymedzenie), súd prvej inštancie konštatoval, že

neuniesla dôkazné bremeno. Žalovaná nepoukázala na konkrétnu reklamáciu, reklamačný list, ale len všeobecne uviedla, že vady spočívajú v oprave prasklín, dilatácií, odpadnutých omietok na 2., 3., 4. nadzemnom podlaží a oprave prasklín, dilatácií a odlepených dlažieb v bytoch č. 3.4, 3.6, 4.2, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.1, 7.6 + náhrada škody (k tomu bližšie bod 43. tohto rozsudku). Súd z tohto vyjadrenia nedokáže posúdiť oprávnenosť čerpania bankovej záruky žalovanou, pričom vyššie súd ustálil, že za statické vady žalobkyňa nezodpovedá. Rovnako súd ustálil, že ak žalovaná namietala rôzny pôvod puklín, bolo jej povinnosťou preukázať, že predmetom väd, kvôli ktorým siahla na bankovú záruku boli nestatické vady. Za daných okolností preto žalovaná, ktorú zaťažuje dôkazné bremeno, nepreukázala, že na bankovú záruku z tohto dôvodu siahla oprávnene. Je preto jej povinnosťou peňažné prostriedky získané z bankovej záruky na základe výzvy z 20.05.2015 žalobkyni vrátiť. Ide o sumu 52.921,24 Eur.

14. V liste zo 04.05.2015 žiadala žalovaná banku o vyplatenie bankovej záruky v sume 38.591,85 Eur za a) opravu odlepenej dlažby na balkóne č. 5.6, b) opravu prasklín na fasáde polyfunkčného domu, c) opravu zatečených rohov v byte č. 7.04, d) opravu prasklín na 2., 3. a 4. nadzemnom podlaží + e) zmluvnú pokutu. Pri písmenách b) a d) žalovaná nepreukázala oprávnenosť použitia bankovej záruky, pričom pri písm. d) žalovaná opätovne neoznačila reklamačné listy a preto neuniesla dôkazné bremeno. Uplatnená suma 825,- Eur za pasportizáciu puklín na 2., 3. a 4. nadzemnom podlaží a za spracovanie prehľadu reklamačných konaní je požadovaná v rozpore so zmluvou o dielo, t. j. bolo siahnuté na bankovú záruku neoprávnene, pretože tá kryje náklady na odstraňovanie väd diela a nie ich skúmanie, evidenciu a spracovanie prehľadu reklamačných konaní. Suma za opravu fasády (reklamácia č. 03/02/2015 Šr z 20.02.2015 - odstránenie 786,40 Eur) je neoprávnene čerpaná, pretože žalovaná nepreukázala, že ide o puklinu, ktorá nemá statický pôvod. Pri zvyšných dvoch reklamáciách, t. j. reklamácia č. 03/11/2012, spočívajúca v odlepenej dlažbe v byte 5.6 a reklamácia č. 01/08/2014, spočívajúca v zle spádovanom balkóne a zavlhnutej stene žalovaná preukázala vynaloženie sumy 35,- Eur za vyspravku zatečených rohov v bytovom dome Centroom byt 7.04 na základe faktúry 3/2015 uhradenej 29.05.2015 dodávateľovi Maroš Mikluš - MIKI. Dohodou o náhrade nákladov za odstránenie reklamovaných závad preukázala žalovaná úhradu sumy 340,21 Eur Z. H. H., ktorý si opravil odlepujúcu sa dlažbu na balkóne č. 5.06. Súdu bol predložený výpis z banky, preukazujúci úhradu sumy 340,21 Eur, ako aj faktúra č. 201210, znejúca na sumu 300,- Eur za prácu a blok v sume 40,21 za materiál. Žalovaná si ale zo sumy 340,21 Eur uplatnila len 333,51 Eur. Tieto vady žalobkyňa preukázateľne neodstránila, pričom v danom prípade ju zaťažovalo dôkazné bremeno preukázať, že odlepená dlažba na balkóne a zatečený roh v byte sú statickými vadami, čo žalobkyňa nepreukázala. Žalobkyňa tak porušila svoju povinnosť v zmysle čl. VI ods. 5 zmluvy o dielo odstrániť reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu. V rovnakom ustanovení zmluva o dielo dáva oprávnenie žalovanej odstrániť vadu inou osobou na náklady žalobkyne, pričom ods. 5 čl. VI zmluvy o dielo oprávňuje náklady súvisiace s odstraňovaním vadného plnenia žalobkyne uspokojiť z bankovej záruky. Uplatnená suma 333,51 Eur a 35 Eur, t. j. 368,51 Eur bola preto z bankovej záruky čerpaná dôvodne.

15. Celková oprávnená suma čerpania bankovej záruky je tak 333,51 Eur + 35,- Eur + 36.605,24 Eur (zmluvná pokuta požadovaná žalovanou - uvedená vo výzve banke zo 04.05.2015). Žaloba žalobkyne je preto v časti istiny 36.973,75 Eur nedôvodná a súd ju zamietol. Vo zvyšku je žaloba žalobkyne dôvodná (91.513,09 Eur - 36.973,75 Eur) a súd zaviazal žalovanú na zaplatenie sumy 54.539,34 Eur žalobkyni, pretože v tomto rozsahu čerpala bankovú záruku nedôvodne, a preto túto sumu musí žalobkyni vrátiť.

16. Ako právne irelevantné (podanie žalobkyne z 31.05.2017) posúdil súd námietky žalobkyne o neprimeranosti zmluvnej pokuty, pretože moderovať môže súd zmluvnú pokutu uplatnenú v konaní, nie zmluvnú pokutu už zaplatenú. Rovnako sú nedôvodné všetky námietky žalobkyne o premlčaní nároku žalovanej, pretože žalovaná žiadny nárok voči žalobkyni neuplatňuje a okolnosť, či v čase siahnutia na bankovú záruku bol nárok žalovanej premlčaný alebo nie je pre tento spor nepodstatná.

17. Súd prvej inštancie priznal žalobkyni aj úrok z omeškania vo výške 8,00% ročne (v súlade s bodom 32. a 33. svojho rozsudku) zo sumy 54.539,34 Eur od 14.05.2016 do zaplatenia. Dátum, od ktorého požaduje žalobkyňa úroky z omeškania bol určený na 14.05.2016, t. j. 10 dní po tom, čo výzva na úhradu z 02.05.2016 zo strany žalobkyne bola doručená žalovanej.

18. O nároku na náhradu trov konania rozhodol súd prvej inštancie v súlade s § 262 ods. 1 C.s.p. v spojení s § 255 ods. 1 a 2 C.s.p., teda podľa zásady úspechu v spore. Žalobkyňa mala v spore úspech v časti o zaplatenie istiny v sume 54.539,34 Eur, čo k žalovanej istine 91.513,09 Eur predstavuje úspech

59,60%. Žalovaná mala úspech v zamietajúcej časti istiny v sume 36.973,75 Eur, čo k žalovanej istine predstavuje úspech 40,40%. Čistý úspech žalobkyne je potom 19,20% (59,60% - 40,40%). Súd preto priznal žalobkyni nárok na náhradu trov konania voči žalovanej v rozsahu 19,20%.

19. Proti tomuto meritórnemu rozhodnutiu súdu prvej inštancie podali obe sporové strany v zákonnej lehote odvolanie.

20. Žalobca svoje odvolanie proti rozsudku súdu prvej inštancie v časti výroku II. v rozsahu 36.605,24 Eur a súvisiacemu výroku III. odôvodnil tým, že súd prvej inštancie vec nesprávne právne posúdil.

21. Žalobca namietal záver súdu prvej inštancie, že moderovať môže súd zmluvnú pokutu uplatnenú v konaní, nie zmluvnú pokutu už zaplatenú. Žalobca považuje toto právne posúdenie za nesprávne, a to z dôvodu, že odporuje ustálenej rozhodovacej praxi najvyšších súdnych autorít, a to najmä s ohľadom na rozsudok veľkého senátu Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 11.4.2018, sp. zn. 31 Cdo 927/2016. Poukázal na to, že v rámci odôvodnenia predmetného rozhodnutia (bod 20) Najvyšší súd Českej republiky uviedol: „Právni úprava moderácie smluvní pokuty v § 301 obch. zák. je kogentní. Strany se nemohou od ní dohodou odchýlit (srov. § 263 obch. zák.). Strany si tak nemohou dohodou vyloučit moderaci smluvní pokuty. Tím spíše nemůže moderaci smluvní pokuty vyloučit jedna ze strany svým jednostranným právním jednáním (zápočtem).“ Ďalej v odôvodnení predmetného rozhodnutia (bod 21 a 23) Najvyšší súd Českej republiky konštatuje, že účelom moderácie je ochrana dlžníka zo zmluvnej pokuty pred neprimerane vysokou zmluvnou pokutou s tým, že k moderácii zmluvnej pokuty nedochádza s účinkami ex nunc, ale ex tunc, k okamihu ujednania o zmluvnej pokute. Ak je zmluvná pokuta neprimeraná, nemôže jednostranným zápočtom dôjsť v rozsahu jej neprimeranej výšky k zániku pohľadávky zo zmluvnej pokuty. Podľa žalobcu súd prvej inštancie rozhodovaciu prax najvyšších súdnych autorít (hoci z Českej republiky, vychádzajúc však z totožného textu právnej normy), pri právnom posúdení opomenul, na posudzovaný prípad nesprávne vylúčil aplikáciu § 301 Obchodného zákonníka, na základe čoho došlo k nesprávnemu právnomu posúdeniu a naplneniu odvolacieho dôvodu podľa § 365 ods. 1 písm. h) Civilného sporového poriadku.

22. Žalobca uviedol, že už v podaní zo dňa 10.5.2021 (strana 13) poukazoval na to, čo by bolo možné považovať za primeranú zmluvnú pokutu (v kontexte zachovania výkladu predmetného ustanovenia zmluvy o dielo tak, aby zmluvná pokuta nebola neprimeraná), a to 2% z hodnoty plnenia, na ktoré sa vada vzťahovala - v danom prípade sa vzťahovala vada na plnenie v sume 333,51 EUR + 35,- EUR (bod 58 odôvodnenia rozsudku), čo je 7,37 EUR. Pre úplnosť je totiž zrejmé, že odstraňovanie väd tretími stranami bolo zabezpečené prostredníctvom bankovej záruky (čo si žalovaný v konečnom dôsledku - o. i. z bankovej záruky aj uplatnil), a teda kompenzačná funkcia zmluvnej pokuty v podobe paušálnej náhrady minimálne skutočnej škody bola dostatočne pokrytá. Žalovaný tiež nepreukázal, že by mu akákoľvek škoda v súvislosti s touto vadou vznikla, a teda je zrejmé, že pri uplatnení § 301 Obchodného zákonníka súd nemusí na žiadnu škodu žalovaného prihliadať.

23. Na základe vyššie uvedených skutočností žalobca navrhuje, aby odvolací súd výrok II. a III. rozsudku súdu prvej inštancie zrušil, vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie a priznal žalobcovi trovy odvolacieho konania v rozsahu 100%, eventuálne, aby odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie zmenil tak, že: I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 91.144,58 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 8% ročne zo sumy 91.144,58 EUR od 14.5.2016 do zaplatenia, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku. II. Vo zvyšku súd žalobu žalobcu zamietla. III. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 99,20%, pričom o výške tejto náhrady bude rozhodnuté Okresným súdom Bratislava I samostatným uznesením.

24. Žalovaný podal odvolanie proti časti výroku I. rozsudku, ktorým súd uložil povinnosť žalovanému zaplatiť žalobcovi sumu 16.086,34 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8% ročne zo sumy 16.086,34 Eur od 14.05.2016 do zaplatenia, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku a žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok v tejto časti zmenil a žalobu zamietol.

25. Uviedol, že čiastka 16.086,34 Eur čerpania z bankovej záruky sa dotýka reklamácií uplatnených u žalobcu. Jednalo sa o škody súvisiace s odstraňovaním následkov vadného plnenia žalobcu. Žalovaný doložil podaním zo dňa 07.10.2021 okrem iného reklamačné listy, z ktorých je zrejmé presné vymedzenie väd, pričom tieto vady nie sú vadami statickými. Žalobca v čase uplatnených reklamácií reklamácie

nerozporoval. V roku 2015 žalovaný písomnou formou uplatnil u zhotoviteľa diela v súlade s čl. VI. ods. 5 zmluvy opodstatnené reklamácie na zhotoviteľom zrealizovanom diele „Výstavba polyfunkčného objektu Centroom“, na ktoré zhotoviteľ vôbec nereagoval. Následne dňa 05.03.2015 žalovaný zhotoviteľovi doporučeným listom doručil zoznam neodstránených reklamovaných závad na objekte, na ktorý žalovaný od zhotoviteľa opakovane nedostal žiadnu odpoveď. Žalobca v čase uplatnených reklamácií už so žalovanou nekomunikoval. Z uvedeného dôvodu musel žalovaný pristúpiť k zabezpečovaniu odstraňovania reklamácií treťou osobou a ním vynaložené náklady si v zmysle zmluvy uplatnil z bankovej záruky za zádržné zriadenej v Slovenskej sporiteľni, a. s. výzvami zo dňa 04.05.2015 a 20.05.2015. Vyplatenú sumu vo výške 16.086,34 Eur z bankových garancií považuje za oprávnenú.

26. Pokiaľ ide o trovy konania, má za to, že existujú dôvody, aby súd nepriznal náhradu trov konania žiadnej strane. Výnimočnosť spočíva v okolnostiach danej veci, porušení povinnosti žalobcu vyplývajúce z čl. VI. ods. 5, 7, 9 zmluvy o dielo č. 2/2009 zo dňa 16.11.2009 (Zodpovednosť za vady/Záruka), že na reklamácie nereagoval a závady neodstraňoval.

27. K odvolaniu žalobcu sa vyjadril žalovaný, ktorý uviedol, že zmluvnú pokutu považoval súd prvej inštancie za platne dojednanú, a preto boli oprávnení siahnuť na bankovú záruku aj titulom zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta zabezpečuje splnenie povinnosti žalobcu odstrániť akúkoľvek vadu v akejkoľvek sume, a preto nemusela byť dohodnutá výška pre konkrétne vady. Žalobca nepreukázal, že by v rámci kontraktačného procesu namietal výšku zmluvnej pokuty. Zmluvu o dielo podpísal (a ako v zmluve o dielo v čl. X ods. 16 vyhlásil - na základe slobodnej, vážnej, určitej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok). Z uvedeného pohľadu je dohoda o zmluvnej pokute vyvážená a nemožno ju považovať za jednostranne zvýhodňujúcu jednu zmluvnú stranu. Použitie moderačného práva je zásahom do zmluvnej voľnosti účastníkov obchodného záväzkového vzťahu. Zásah súdu do zmluvných vzťahov aplikáciou § 301 Obchodného zákonníka by mal byť výnimočným postupom. Stotožňuje sa s právnym záverom súdu prvej inštancie, že námietky žalobcu o neprimeranosti zmluvnej pokuty sú právne irelevantné, pretože moderovať môže súd zmluvnú pokutu uplatnenú v konaní, nie zmluvnú pokutu už zaplatenú. Uvádza tiež, že ich postup nemožno hodnotiť ako rozporný s poctivým obchodným stykom, pretože realizovali oprávnenia zo zmluvy o dielo, na ktorých sa so žalobcom vyslovene dohodli.

28. Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného namietal, že žalovaný len uviedol, že sa nestotožňuje so skutkovými a právnymi závermi súdu prvej inštancie; je však zrejmé, že žalovaný ani neuviedol, že by bol skutkový stav nesprávne zistený na základe vykonaných dôkazov (len to, že považuje vyplatenie sumy z bankovej záruky za oprávnenú, neuviedol však žiadny súvisiaci odvolací dôvod) alebo že by súd prvej inštancie vec po právnej stránke nesprávne posúdil, a teda žiadny odvolací dôvod v kontexte § 363 CSP neuviedol.

29. Poukázal na to, že v časti II. odvolania žalovaný uviedol skutkové tvrdenia, ktoré buď zrekapituloval, prípadne uviedol nové skutkové tvrdenia, a to, že žalobca v čase uplatnených reklamácií reklamácie nerozporoval. Žalovaný prvý raz v konaní uvádza, že žalobca reklamácie nerozporoval, čo žalobca považuje za nové skutkové tvrdenie (žalovaný takéto tvrdenie uviedol prvý raz). Podľa jeho názoru ide o takú novotu v podobe nového skutkového tvrdenia, ktoré nespĺňa požiadavky uvedené v § 366 CSP, a teda v tomto smere nie je možné na nové skutkové tvrdenia prihliadať. Žalobca z opatrnosti poukazuje na to, že okrem vyššie uvedeného je tvrdenie v rozpore so zisteným skutkovým stavom, nakoľko samotný žalobca už v replike z 31.5.2017 poukázal na časovú genézu prípadu, a to, že medzi žalobcom a žalovaným bola uzatváraná dohoda v súvislosti s odstraňovaním väd a pomeru znášania súvisiacich nákladov na odstraňované vady (obdobie 2012 - 2014), na základe ktorej boli vady (a pomer znášania nákladov na ich odstraňovanie medzi žalobcom a žalovaným) riešené, a teda uvedené tvrdenie žalovaného je v rozpore so zisteným skutkovým stavom.

30. K návrhu žalovaného, aby súd nepriznal náhradu trov konania žiadnej strane, pričom mal za to, že na to existujú dôvody a že výnimočnosť spočíva v okolnostiach - porušenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy (čl. VI, ods. 5, 7 a 9) uviedol, že žiadne okolnosti na nepriznanie náhrady trov konania podľa pomeru úspechu žalobcovi dané nie sú, zo skutkového stavu a vykonaného dokazovania v rámci konania na súde prvej inštancie vyplynulo, že žalobca za žalovaným uplatňované vady nezodpovedal. V zmysle čl. VI bod 9 Zmluvy vyplýva, že ak žalobca zodpovednosť za vady popiera, je povinný ich uhradiť len v prípade, ak ich odstránenie neznesie odklad. Zároveň v niektorých prípadoch čerpania

bankovej záruky neuplynuli lehoty v Zmluve, na ktoré žalovaný odkazuje (lehoty na odstránenie väd, úhrada nákladov tretích strán).

31. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací podľa § 34 zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len C.s.p.) prejednal vec podľa § 380 ods. 1 bez nariadenia pojednávania v medziach daných rozsahom a dôvodmi odvolania, pričom termín verejného vyhlásenia rozsudku bol v súlade s ust. § 219 ods. 3 C.s.p. oznámený na úradnej tabuli a webovej stránke Krajského súdu v Bratislave dňa 4.6.2024. Po oboznámení sa s obsahom spisu súdu prvej inštancie a dôvodmi odvolania žalobcu i žalovaného dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.

32. Odvolací súd z obsahu spisu zistil, že právny predchodca žalobcu (BK Construction, s.r.o.) a žalovaný uzavreli dňa 16.11.2009 zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zabezpečiť pre objednávateľa vykonanie diela - výstavbu polyfunkčného objektu v Piešťanoch na ulici Nitrianska. V čl. IV ods. 4.3 zmluvy o dielo sa žalobca zaviazal preveriť všetky zvislé a vodorovné nosné a nenosné monolitické a murované konštrukcie, všetky pripomienky ku kvalite, zvislosti a vodorovnosti zhotoveným zvislým a vodorovným nosným a nenosným monolitickým a murovaným konštrukciám musia byť písomne predložené objednávateľovi najneskôr 10 dní po prevzatí stavby resp. podpisom zmluvy. Žalobca tvrdil, že si uvedenú povinnosť splnil a v listine požiadavky na stavebnú pripravenosť a zápis z prevzatia murárskych konštrukcií poukázal na to, že nerovnosti stropov vykazujú priehyby 4 - 5 cm. Zmluva o dielo umožňovala žalobcovi ako zhotoviteľovi nahradenie garančného zádržného vo výške 5% z ceny diela bankovou zárukou vystavenou v prospech žalovaného ako objednávateľa. Bankovú záruku č. 377/AUOC/05-52 na žiadosť žalobcu vystavila Slovenská sporiteľňa, a.s. v prospech žalovaného. Dielo bolo žalovanému riadne odovzdané, čo potvrdzuje zápis o odovzdaní a prevzatí č. 08/2010. Žalovaný sa následne žiadosťou zo 04.05.2015 domáhal voči banke čerpania bankovej záruky v sume 38.591,85 Eur a žiadosťou z 20.05.2015 v sume 52.921,24 Eur. Tieto peňažné prostriedky boli žalovanému vyplatené 07.05.2015 a 21.05.2015. Podľa žalobcu neboli splnené podmienky pre čerpanie bankovej záruky, predmetom konania je teda nárok na vrátenie uplatnenej bankovej záruky. Podľa súdu prvej inštancie žalovaný neuniesol dôkazné bremeno, že si uplatnil bankovú záruku za vady, ktoré nie sú vadami statickými s výnimkami uvedenými v ods. 55 až 58 rozsudku. Súd prvej inštancie dospel k záveru, že v rozsahu zmluvnej pokuty v sume 36.605,24 EUR (zmluvná pokuta požadovaná žalovaným v zmysle výzvy banke zo 4.5.2015) je banková záruka čerpaná oprávnená. Okrem toho súd prvej inštancie dospel k záveru, že v súvislosti s potrebou zabezpečenia väd tretími stranami bola čerpaná banková záruka oprávnená iba v rozsahu 333,51 EUR a 35,- EUR, t. j. spolu 368,51 EUR (odsek 58 odôvodnenia rozsudku).

33. Odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutom rozsahu výroku I. (suma 16.086,34 Eur s príslušenstvom), keďže dospel k záveru, že odvolaniu žalovaného nie je možné vyhovieť. Žalovaný v odvolaní uviedol, že sa nestotožňuje s právnymi a skutkovými závermi v napadnutej časti. Poukázal na to, že doložil podaním zo dňa 7.10.2021 reklamačné listy, z ktorých je zjavné presné vymedzenie väd, pričom tieto vady nie sú vadami statickými a žalobca ich v čase uplatnených reklamácií nerozporoval.

34. V právnej úprave civilného sporového konania platí, že odvolací súd je v zmysle § 380 C.s.p. viazaný odvolacími dôvodmi, z dôvodu čoho súd v odvolacom konaní ex offo nezisťuje iné dôvody než tie, ktoré uplatnil odvolateľ. Žalovaný v odvolaní uplatnil odvolací dôvod podľa § 365 ods. 1 písm. f) C.s.p., kedy súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. Uplatnený odvolací dôvod podľa § 365 ods. 1 písm. f) je v súdnej praxi vykladaný tak, že musí ísť o také skutkové zistenia, na základe ktorých súd prvej inštancie vec posúdil po právnej stránke a ktoré nemali v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní. Skutkové zistenia nezodpovedajú vykonaným dôkazom, ak výsledok hodnotenia dôkazov nie je v súlade s § 191 CSP, a to vzhľadom na to, že súd vzal do úvahy len skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplynuli ani inak nevyšli počas konania najavo, alebo opomenul rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, alebo vyšli počas konania najavo. Nesprávne sú aj také skutkové zistenia, ktoré súd prvej inštancie založil na chybnom hodnotení dôkazov. Typovo ide o situáciu, kde logický rozpor v hodnotení dôkazov, prípadne poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov strán alebo ktoré vyšli inak najavo z hľadiska závažnosti (dôležitosti) zákonnosti, pravdivosti, eventuálne vierohodnosti alebo ak výsledok hodnotenia dôkazov nezodpovedá tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z civilného sporového poriadku o vykonávaní dokazovania.



35. Odvolací dôvod podľa § 365 ods. 1 písm. h) CSP, nesprávne právne posúdenie veci, je chybnou aplikáciou práva na zistený skutkový stav; dochádza k nej vtedy, ak súd nepoužil správny (náležitý) právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery. Súd pri tejto činnosti rieši právne otázky (questio iuris), ich riešeniu predchádza riešenie skutkových otázok (questio facti), teda zistenie skutkového stavu.

36. Odvolací súd konštatuje, že žalovaný síce ako odvolací dôvod uviedol nesprávne skutkové a právne závery, ale neidentifikoval v akom konkrétnom pochybení vidí naplnenie odvolacieho dôvodu nesprávne právne posúdenie. Pokiaľ ide o nesprávne zistený skutkový stav, namietal, že z reklamačných listov predložených podaním zo dňa 7.10.2021 je zrejmé, že nešlo o vady statické a žalobca ich nerozporoval. Odvolací súd predovšetkým uvádza, že žalovaný nekonkretizuje vo svojom odvolaní konkrétne ktorých väd a reklamácií sa má nesprávne zistený skutkový stav týkať a ktoré reklamované vady v čase ich uplatnenia žalobca nereklamoval. Odvolací súd z obsahu spisu nezistil, že by žalovaný použil takýto prostriedok procesnej obrany v prvoinštančnom konaní, preto musí konštatovať, že ide o neprípustnú novotu v odvolacom konaní (§ 366 C.s.p.), naviac nie je zrejmé, čo touto argumentáciou zamýšľal odvolateľ dosiahnuť.

37. Podľa odvolacieho súdu sa súd prvej inštancie dostatočne v odôvodnení rozsudku vysporiadal s tým, v ktorých prípadoch bola čerpaná banková záruka nedôvodne, keď náležitým spôsobom odôvodnil, že žalobca nenesie zodpovednosť za statické vady a podrobne sa vysporiadal s vadami, neodstránenie ktorých bolo predmetom výziev zo dňa 4.5.2015 a 20.5.2015 na zaplatenie bankovej záruky.

38. Vzhľadom na uvedené odvolací súd rozsudok v napadnutom rozsahu výroku I. ako vecne správny podľa § 387 ods. 1, 2 C.s.p. potvrdil.

39. Na základe odvolania žalobcu preskúmal odvolací súd aj výrok II. v napadnutom rozsahu (36.605,24 Eur), ktorým súd prvej inštancie žalobu vo zvyšku zamietol.

40. Ako vyplýva z odôvodnenia napadnutého rozsudku, súd prvej inštancie žalobu vo zvyšku zamietol v rozsahu požadovaného vrátenia neoprávnene uplatnenej bankovej záruky, ktorá sa vzťahuje na zmluvnú pokutu (v celej sume 36.605,24 Eur). Súd prvej inštancie ako právne irelevantné posúdil námietky žalobcu o neprimeranosti zmluvnej pokuty obsiahnutej v podaní žalobcu zo dňa 31.5.2017, pretože dospel k záveru, že moderovať môže súd zmluvnú pokutu uplatnenú v konaní, nie zmluvnú pokutu už zaplatenú. Vzhľadom na uvedené súd prvej inštancie dospel k záveru, že v rozsahu zmluvnej pokuty v sume 36.605,24 EUR (zmluvná pokuta požadovaná žalovaným v zmysle výzvy banke zo 4.5.2015) je banková záruka čerpaná oprávnene. Okrem toho súd prvej inštancie dospel k záveru, že v súvislosti s potrebou zabezpečenia väd tretími stranami bola čerpaná banková záruka oprávnene iba v rozsahu 333,51 EUR a 35,- EUR, t. j. spolu 368,51 Eur (bod 58 odôvodnenia rozsudku). Žalobca pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností v odvolaní uviedol, že sa s odôvodnením vo vzťahu k výroku I. rozsudku v plnom rozsahu stotožňuje a vo vzťahu k výroku II. rozsudku napáda tento výrok iba v rozsahu 36.605,24 EUR (výlučne vo vzťahu k zmluvnej pokute, ktorá bola podľa žalobcu uplatnená z bankovej záruky neoprávnene, je neprimeraná a žiadal, aby súd v súlade s § 301 Obchodného zákonníka uplatnil moderačné právo). Žalobca vymedzil ako odvolací dôvod nesprávne právne posúdenie možnosti uplatnenia moderačného práva súdu.

41. Podľa § 301 Obchodného zákonníka, neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 <aspi://module='ASPI'&link='513/1991 Zb.%2523373'&ucin-k-dni='30.12.9999'> a nasl.

42. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že moderačné (zmierňovacie) právo (ius moderandi) prislúcha súdu, ide teda o sudcovské právo. Spočíva v tom, že súd môže na návrh rozhodnúť, že zmluvnú pokutu neprizná v celej výške, t. j. vo výške, v akej bola stranami dohodnutá, aj keď veriteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vznikol nárok. Zákon teda umožňuje súdu zasiahnuť do zmluvných vzťahov a tieto vzťahy medzi účastníkmi modifikovať. Súd nemôže zmluvnú pokutu odpustiť. Účelom moderačného

práva je umožniť súdu dodatočne po vzniku nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty znížiť zmluvnú pokutu z dvoch dôvodov. Predovšetkým preto, aby bolo možné odstrániť tvrdosť zákona, ku ktorej môže dôjsť pri prísnom uplatňovaní litery zákona, ale tiež preto, aby mal súd v konkrétnom prípade možnosť zabrániť celkom neadekvátnym majetkovým dôsledkom v prípade, keď by neprimerane vysoká zmluvná pokuta mohla viesť až k neprimeraným ziskom vo vzťahu k majetkovej ujme na strane oprávneného a k neprimeranému (vo vzťahu k porušenej povinnosti) hospodárskemu poškodeniu povinného subjektu, prípadne až k jeho likvidácii. Naplnenie moderačného práva spočíva v tom, aby súd mohol uvážiť všetky okolnosti konkrétneho prípadu a práve týmto konkrétnym okolnostiam podriadil aj svoje rozhodnutie.

43. Odvolací súd sa stotožnil s odvolacou námietkou žalobcu, že súd prvej inštancie nesprávne právne posúdil možnosť uplatnenia moderačného práva, resp. že nesprávne aplikáciu tohto ustanovenia vylúčil. Odvolací súd poukazuje predovšetkým na skutočnosť, že súd prvej inštancie svoj právny názor, že „moderovať môže súd zmluvnú pokutu uplatnenú v konaní, nie zmluvnú pokutu už zaplatenú“ žiadnym spôsobom neodôvodnil. Tento názor nepodoprel ustanovením zákona, ani súdnou praxou a ani túto svoju úvahu nevysvetlil. Podľa názoru odvolacieho súdu zo zákona ani zo súdnej praxe nevyplýva, že by súd nemal právomoc znížiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu, ak už bola dlžníkom uhradená. Podmienkou, aby sa súd moderačným právom zaoberal, je návrh dlžníka o jej zníženie v súdnom konaní. Predmetom tohto konania je nárok na vrátenie plnenia z bankovej záruky, ktoré zahŕňa aj zmluvnú pokutu, žalobca teda nezaplatil zmluvnú pokutu dobrovoľne, zaplatenie zmluvnej pokuty sa uskutočnilo formou plnenia z bankovej záruky. Skutočnosť, že zmluvná pokuta nie je uplatnená ako samostatný nárok veriteľa v súdnom konaní, nie je dôvodom, aby súd vylúčil aplikáciu citovaného ustanovenia.

44. Odvolací súd sa stotožnil s názorom žalobcu, že ak je zmluvná pokuta uplatnená z bankovej záruky a predmetom konania je vrátenie plnenia, je na posudzovaný prípad aplikovateľný rozsudok veľkého senátu Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 11.4.2018, sp. zn. 31 Cdo 927/2016 podľa ktorého (bod 20): „Právni úprava moderácie smluvní pokuty v § 301 obch. zák. je kogentní. Strany se nemohou od ní dohodou odchýlit (srov. § 263 obch. zák.). Strany si tak nemohou dohodou vyloučit moderaci smluvní pokuty. Tím spíše nemůže moderaci smluvní pokuty vyloučit jedna ze strany svým jednostranným právním jednáním (zápočtem).“

45. Podľa odvolacieho súdu účelom moderácie je ochrana dlžníka zo zmluvnej pokuty pred neprimerane vysokou zmluvnou pokutou s tým, že k moderácii zmluvnej pokuty nedochádza s účinkami ex nunc, ale ex tunc, k okamihu dojednania o zmluvnej pokute. Ak je zmluvná pokuta neprimeraná, nemôže jednostranným zápočtom dôjsť v rozsahu jej neprimeranej výšky k zániku pohľadávky zo zmluvnej pokuty. Ako už bolo uvedené, citovaný rozsudok je uplatniteľný aj na prípad, ak je zmluvná pokuta uplatnená z bankovej záruky a predmetom konania je vrátenie plnenia z bankovej záruky, t. j. na posudzovaný prípad, a teda súd prvej inštancie bol povinný sa vysporiadať so zmluvnou pokutou podľa § 301 Obchodného zákonníka a nemal aplikáciu tohto ustanovenia vylúčiť a posúdiť túto požiadavku žalobcu ako právne irelevantnú.

46. Odvolací súd na záver uvádza, že Občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na zasadnutí 10. októbra 2018 prijalo ako judikát rozhodnutie z 24. januára 2018 sp. zn. 6 Cdo 29/2017, právna veta ktorého znie: „Do ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu v zmysle § 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku treba zahrnúť aj naďalej použiteľné, legislatívnymi zmenami a neskoršou judikatúrou neprekonané civilné rozhodnutia a stanoviská publikované v Zbierkach súdnych rozhodnutí a stanovísk vydávaných Najvyššími súdmi ČSSR a ČSFR, ďalej v Bulletin Najvyššieho súdu ČSR a vo Výbere rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu SSR a napokon aj rozhodnutia, stanoviská a správy o rozhodovaní súdov, ktoré boli uverejnené v Zborníkoch najvyšších súdov č. I, II. a IV vydaných SEVT Praha v rokoch 1974, 1980 a 1986.“ Na túto argumentačnú líniu nadviazal NSSR aj v ďalšom rozhodnutí (Uznesenie NSSR, sp. zn. 3 Cdo 165/2018 <<http://merit.slv.cz/3Cdo165/2018>> zo dňa 22. novembra 2018), kde uvádza, že cit. „Pod pojem ustálenej súdnej praxe a pod pojem dovolací súd v zmysle § 421 ods. 1 CSP <<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/>> teda nemožno zahrnúť rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky, na ktoré žalobca poukazuje vo svojom dovolaní, ani Najvyšší súd Českej republiky.“

47. Možno teda konštatovať, že citovaný rozsudok sice nepredstavuje ustálenú súdnu prax najvyšších súdnych autorít záväznú pre slovenské všeobecné súdy, avšak vzhľadom na rovnakú právnu úpravu je možné zo záverov citovaného rozsudku vychádzať.

48. Odvolací súd preto rozsudok v napadnutom rozsahu výroku II. podľa § 389 ods.1 písm. b), c) C.s.p. zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. Úlohou súdu prvej inštancie bude vysporiadať sa s návrhom žalobcu na zníženie zmluvnej pokuty, t.j. posúdiť, či je dôvod na uplatnenie moderačného práva.

49. O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 396 ods. 3 C.s.p. Keďže odvolací súd rozhodnutie v napadnutom rozsahu výroku II. zrušil, zrušil aj súvisiaci výrok o trovách konania. O trovách konania rozhodne opätovne súd prvej inštancie s tým, že sa vysporiada aj s tvrdeniami žalovaného v odvolacom konaní, týkajúcimi sa náhrady trov konania.

50. Toto rozhodnutie bolo členmi senátu prijaté pomerom hlasov 3:0 (§ 393 ods. 2, veta druhá C.s.p.).

#### **Poučenie:**

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii.

Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.).